

1501126-62.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... já decidiu o Tribunal de Justiça, "Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501126-62.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501126-62.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

EDMILSON FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de abril de 2022, por volta das 22h40minutos, na Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filhos, altura do número 1628, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo, para fim de tráfico, 122 porções de "crack", 109 porções de cocaína em pó, 79 frascos de lança perfume, 37 porções de Cannabis sativa L e 16 unidades de LSD, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo drogas com a finalidade de traficar.

Ocorre que, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro na região, e avistaram o réu com uma sacola nas mãos que, ao perceber a aproximação da viatura, correu.

Diante da fundada suspeita que recaia sobre Edmilson, os agentes da autoridade foram no seu encalço e o detiveram.

Realizada busca pessoal, em poder dele, os milicianos lograram apreender a sacola contendo a expressiva quantidade e diversidade de drogas e a quantia acima mencionadas.

Edmilson confessou que estava ali traficando drogas.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia e analisada a defesa apresentada, foi o réu citado e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a observância da reincidência específica e imposição de regime inicial fechado.

A defesa, preliminarmente, requereu a juntada do laudo referente às anotações apreendidas nos autos. Alegou, outrossim, a ilicitude das provas, porquanto derivadas de revista pessoal ilegal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, sustentou que a negativa de autoria ofertada pelo acusado não restou dissociada das provas coligidas aos autos. Em caso de entendimento diverso, pediu a fixação da pena-base no patamar legal; reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; imposição de regime inicial diverso do fechado, observando-se a detração e o direito de recorrer solto.

Juntado o laudo pericial pleiteado pela defesa, aberta vista dos autos às partes, que ratificaram as alegações finais apresentadas em audiência.

RELATADO.

DECIDO.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos policiais militares, considerando que são eles imbuídos do poder de polícia que é próprio do Poder Público.

Sendo assim, quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo

Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

No mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do dinheiro e dos papéis contendo anotações, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 39/41, 163/168, 169/171 e 172/174), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica; pelo exame pericial de fls. 180/188 e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu confessou a traficância. Em Juízo, retratou-se, negando a prática delitiva. Disse que voltava da casa da namorada e tinha em seu poder apenas a quantia de R\$ 42,00. Ao constatarem que tinha antecedentes, um dos policiais pegou uma sacola contendo drogas e o ameaçou, dizendo que se não entregasse uma arma, uma "bomba" ou um "foragido da justiça", o levaria para delegacia por tráfico. Negou, ainda, ter confessado na delegacia, afirmando que assinou seu depoimento obrigado pela autoridade policial.

Sucede que tal negativa, seguida de versão inverossímil, restou isolada nos autos e não merece credibilidade, cumprindo observar que a confissão policial, desde que corroborada por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório.

No tocante à confissão policial, já decidiu o Tribunal de Justiça, "Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico" (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. de 08/01/2009)." (Apelação Criminal nº 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016)

E mais, "É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil". (Apelação Criminal nº 9230875-35.2008.8.26.0000, Rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. de 10/05/2012).

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Caio Martins Bento e Jonathan de Freitas, policiais militares que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas e do dinheiro em poder do réu. Relataram, ainda, que ao notar a presença da viatura o acusado correu com uma sacola nas mãos, em cujo interior havia cocaína, maconha, LSD e lança-perfume, além cédulas de valores diversos. O réu não chegou a jogar a sacola ao solo durante a fuga.

E as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova. Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

As substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu EDMILSON FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/5 (um quinto), somando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista a quantidade e variedade de tóxico apreendida em poder do réu.

Note-se que a "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006" (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Possível o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, não se podendo afirmar que tal prova tenha sido produzida apenas no inquérito, sendo inegável seu valor e servindo como base de decidir ainda que não fosse o único elemento incriminador, porquanto ratificado pelos depoimentos dos policiais em juízo.

Veem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que a confissão, uma vez empregada para fundamentar a decisão, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que parcial ou apenas na fase de inquérito.

"(...) 5. A confissão do Agravante de que exercia a traficância, efetivada na fase policial, foi utilizada para fundamentar a condenação. Portanto, ainda que tenha sido retratada em juízo, faz ele jus à atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior. [...] 7. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para aplicar a atenuante da confissão e compensá-la, integralmente, com a reincidência, bem assim reconhecer a desproporcionalidade e diminuir o quantum de aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto." (AgRg no AREsp nº 1795241/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 15/04/2021).

Dessa forma, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida, o que demonstra a dedicação do acusado ao crime, além da reincidência específica.

A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

Inaplicável o instituto da detração penal ao réu, conforme dispõe a Lei nº 12.736/12, ante as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente e, ainda, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.

Ao incluir o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogou o artigo 33, § 3º, do Código Penal, nem tampouco o artigo 59, inciso III, do mesmo Códex.

E, no caso concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis para a fixação de regime inicial menos gravoso.

Assim, não obstante o previsto no artigo 387, § 2º, da Lei nº 12.736/2021 e, “data vênia” dos entendimentos contrários, bem como sendo impossível a este Juízo sopesar a presença dos requisitos subjetivos, incabível a aplicação da detração penal.

Nesse sentido, "(...) 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido". (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, DJ 10/10/2014).

Incabível, portanto, a detração penal ao sentenciado, cabendo ao Juízo da Execução a sua aplicação.

O réu não poderá apelar em liberdade, eis que continuam presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu EDMILSON FERREIRA DA COSTA, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 11 de agosto de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito